KINX2007003632

취업규칙의 불이익 변경과 효력

구 건 서 _ 열린노무법인 대표공인노무사

구건서 공인노무사는 현재 열린노무법인 대표와 중앙노사교육원 원장, 한국노동교육원 객원교수로 활동하고 있다.
지금까지 '노사혁신프로젝트' '중소기업형 연봉제' '새노동법 해설' 등 10권의 전문서적을 집필하였으며 공인노무사시험 출제위원을 역임했다.
'노사관계 혁신' 새로운 노사문화' 등 노사관계 경제력을 높이기 위한 교육과 강의, 자문과 컨설팅을 통해서 노사공존의 철학을 현장에 뿌리내리는 역할을 해왔다.

1 취업규칙이란 무엇인가

취업규칙은 사업장내에서 노사가 모두 지켜야할 근무조건, 복무규율 등에 관하여 정한 규칙을 의미한다. 상시 10인 이상의 사업장에서는 근로기준법 제96조의 규정에 따라 의무적으로 작성하여 이를 노동부장관에 신고하도록 되어있다.

이러한 취업규칙은 노동조합이 없는 사업장에서는 기업의 헌법으로서 가장 주요한 근로조건규범이 된다. 실무적으로 사규, 복무규정, 임금규정, 상여금규정 등으로 별도의 명칭으로 불리어지고 있으나 명칭이야 어떻든 사업장의 전근로자에게 적용되는 근로조건 등을 포함하고 있다면 취업규칙으로 보아야 한다.

취업규칙은 사용자가 일방적으로 작성 · 변경할 수 있지만 법령에 위반되지 않는 범위 내에서 그 효력이 인정된다. 근로기준법 제99조에서도 "취업규칙은 법령 또는 당해 사업장에 대하여 적용되는 단체협약에 반할 수 없다"라고 규정하여 이를 확인하고 있다. 만약 법령에 위반되는 취업규칙이 있다면 당연히 무효가 되고 노동부장관의 변경명령을 받게 된다.

또한 단체협약은 '노사 간의 헌법'으로서 노사간에 합의를 통해서 만들어진 것이기 때문에 사용자 일방이 작성하는 취업규칙보다 우월한 효력을 가진다. 즉 단체협약은 헌법 제33조에서 규정하고 있는 단결권, 단체교섭권, 단체행동권 등 노동3권의 보장결과 대등한 입장에서 노사 간에 협약으로 맺은 것이므로 근로계약이나 취업규칙보다 우선적으로 적용되는 것이다.

노조법 제33조에서도 "단체협약에 정한 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준에 위반하는 취업규칙 또는 근로계약의 부분은 무효로 하며 무효로 된 부분은 단체협약에 정한 기준에 의한다"라고 규정하고 있다. 그리고 취업규칙은 다수의 근로자를 예정하고 있으나 근로계약은 개별근로자를

상대로 작성되는 것이므로 취업규칙이 근로계약에 우선하는 효력을 가진다.

근로기준법 제100조에서는 "취업규칙에 정한 기준에 미달하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 관하여는 무효로 한다. 이 경우에 있어서 무효로 된 부분은 취업규칙에 의한다"라고 규정하고 있다.

2 취업규칙의 작성 및 변경권

취업규칙을 작성하고 변경하는 권한은 사용자에게 주어져 있다. 근로관계의 일방 당사자인 사용자에게 일방적인 작성 및 변경권을 인정한 근거에 대하여는 논란이 있으나 노사관계의 합리적인 규율과 근로자보호라는 측면에서 그 근거를 찾고 있다. 근로기준법 제96조에서는 "상시 10인 이상의 근로자를 사용하는 사용자는 취업규칙을 작성하여 노동부장관에게 신고하여야 한다. 이를 변경하는 경우에 있어서도 또한 같다"라고 하여 사용자에게 작성 · 변경권이 있음을 명시하고 있다.

다만 공정한 기준을 설정할 수 있도록 두 가지의 제약을 가하고 있다.

첫째, 절차적인 제약으로서는 작성 · 변경시 근로자들의 의견을 듣도록 하고 있다. 만약 불이익한 변경이라면 근로자들의 동의가 필요하다. 동의의 주체는 근로자 과반수 이상으로 조직된 노동조합이 있으면 그 노동조합, 그러한 노동조합이 없으면 근로자 과반수의 의견을 들어야 한다. 사용자는 근로자들의 의견에 구속을 받지 않는다. 절차적으로 의견을 듣는 것으로 충분하다.

둘째, 실질적인 제약으로는 법령이나 단체협약의 기준에 미달하지 않아야 한다. 사용자에게 작성 · 변경권을 주되 실질적, 절차적인 제약을 통하여 사업장내에서 공정하고 합리적인 근로조건이 실행되도록 감시하는 것이다.

과반수 이상으로 조직된 노조가 없는 경우에는 근로자 과반수의 의견을 듣도록 하고 있는데 전체 근로자 과반수 이상만 서명하면 되는 것인지 아니면 근로자 과반수를 대표하는 자를 선출해서 선출된 대표의 의견을 들으면 되는지 해석에 차이가 있다. 법에는 분명히 "근로자의 과반수의 의견"이라고 명시되어 있다. 이를 그대로 적용하면 사업장에 근무하는 근로자 과반수 이상의 의견을 들으면 된다.

그러나 판례는 "사용자측의 개입이나 간섭이 배제된 상태에서 근로자들의 자주적인 의견의 집약에 의한 과반수(집단적 의사결정방법)"라는 입장이다(대판 1993. 3. 12, 92다15086). 여기에서 집단적 의사결정방법이라 함은 "반드시 한 사업 또는 사업장의 전 근로자가 한 자리에 집합하여 회의를 개최하는 방식만이 아니라 한 사업 또는 사업장의 단위부서별로 근로자 상호간에 의견을 교환하여 찬반의 의견을 집약한 후 이를 전체적으로 취합하는 방식도 허용된다"(대판 1993. 8. 24, 93다17898)라고 판결하고 있다.

한편 취업규칙 변경내용을 공람케 하고 서명을 받는 방법을 생각할 수 있는데, 이때는 사용자측의 개입 · 간섭이 배제된다는 것이 객관적으로 입증될 수 있다면 허용된다고 해석된다. 또한 노동부에서도 "근로자수가 많아 집단적 의사결정방식을 취하기 어려운 경우 '근로조건 변경 예고제'를 시행해도 무방하며 근로기준법에 의한 의견을 들을 의무를 이행한 것으로 볼 수 있으려면 근로자에게 배포하고 회람 후 서명토록 하는 등 근로자 과반수의 의견을 들었다는 것이 객관적으로 증명되어야 함"(근기 01254-12348, 1991. 8. 28)이라고 하고 있다.

3 취업규칙을 불리하게 변경하는 절차

취업규칙을 불리하게 변경하려면 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있으면 그 노동조합, 그러한 노동조합이 없으면 근로자 과반수의 동의를 얻어야 한다. 지금까지 시행되던 취업규칙 내용 중 근로조건, 복무규율 등을 근로자에게 불리하게 변경하는 것을 취업규칙의 불이익변경이라 한다.

취업규칙은 근로자 전체에 적용될 근로조건을 명시하고 있으므로 기업에서 그동안의 근로조건을 불리하게 변경하려면 반드시 취업규칙을 변경해야 하는데 우리나라에서는 주로 퇴직금누진제를 법정제로 변경하면서 발생되는 문제가 많았다. 또한 IMF사태를 맞아 각 기업이 위기극복이라는 목표를 달성하기 위하여 근로조건을 변경하는 과정에서 많은 다툼이 있었다.

주40시간제를 도입하면서 개정법의 취지에 따라 취업규칙을 변경하는 것도 월차휴가를 폐지하고 생리휴가를 무급으로 규정하는 경우는 불이익 변경으로 해석될 여지가 있다. 취업규칙에 별다른 조항을 명시하지 않고 단순히 "월차휴가는 근로기준법에 따른다"라거나 "생리휴가는 근로기준법에 따른다"라고 규정하고 있었다면 법 개정과 동시에 개정된 내용을 취업규칙이 인정한 것이므로 불이익변경에 해당하지 않는다. 그러나 월차휴가와 생리휴가를 별도로 규정하고 있었다면 이를 폐지하거나 무급으로 변경하는 것은 취업규칙의 불이익 변경에 해당한다.

취업규칙의 불이익 변경여부는 사회통념상 합리성이 있는지에 따라 객관적 기준의 입장이 판례와 행정해석(근기 01254-16545, 1991. 11. 5)의 태도이다. 근로자 한사람이라도 불리하다면 일단 불이익 변경으로 보아야 할 것이며 이러한 판단기준은 변경내용, 변경의 필요성, 변경절차 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

4 동의를 얻지 않은 경우의 효력

취업규칙을 불리하게 변경하는 것은 근로계약의 당사자인 근로자들의 대표기관인 노동조합이나 근로자대표의 동의가 반드시 필요하며 이러한 동의를 얻지 않은 취업규칙의 불이익 변경은 변경으로서의 효력이 없다. 즉 절차를 제대로 거치지 않은 취업규칙은 변경의 효력이 없기 때문에 변경된 취업규칙은 효력이 없고 오히려 변경되기 전의 종전 취업규칙이 작용되는 것은 당연하다. 따라서 이렇게 해석할 경우 변경 이전에 입사한 근로자는 물론 변경 이후에 입사한 근로자도 종전 취업규칙을 적용받게 된다.

그런데 1992. 12. 22, 91다 45165 전원합의체 판결에서는 이러한 절대무효의 입장을 변경하여 변경 후 변경된 내용을 알고 입사한 근로자는 변경된 취업규칙이 적용된다는 상대적 효력을 인정하는 쪽으로 바뀌었다. 즉 이 판결에서 대법원은 "사용자가 취업규칙에서 정한 근로조건을 불리하게 변경함에 있어서 근로자의 동의를 얻지 않은 경우에 그 변경으로 기득이익이 침해되는 기존의 근로자에 대한 관계에서는 그 변경의 효력이 미치지 않게 되어 종전 취업규칙의 효력이 그대로 유지되지만, 그 변경 후에 변경된 취업규칙에 따른 근로조건을 수용하고 근로관계를 갖게 된 근로자에 대한 관계에서는 당연히 변경된 취업규칙이 적용되어야 한다"라고 하여 새로 변경된 이후에 입사한 근로자

◉ 판 례

근로자의 동의 없이 불리하게 변경된 취업규칙은 기존 근로자에게는 무효이지만 변경 후 새로 입사한 근로자에는 변경된 취업규칙이 적용되어야 한다. (1992.12.22, 대법 91다 45165)

취업규칙의 작성 · 변경에 관한 권한은 원칙적으로 사용자에게 있으므로 사용자는 그 의사에 따라 취업규칙을 작성 · 변경할 수 있으나, 다만 근로기준법 제95조의 규정에 의하여 노동조합 또는 근로자 과반수의 의견을 들어야 하고, 특히 근로자에게 불이익하게 변경하는 경우에는 그 동의를 얻어야 하는 제약을 받는 바, 기존의 근로조건을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에 필요한 근로자의 동의는 근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의임을 요하고 이러한 동의를 얻지 못한 취업규칙의 변경은 효력이 없다. 사용자가 취업규칙에서 정한 근로조건을 근로자에게 불리하게 변경함에 있어서 근로자의 동의를 얻지 않은 경우에 그 변경으로 기득이익이 침해되는 기존의 근로자에 대한 관계에서는 그 변경의 효력이 미치지 않게 되어 종전 취업규칙의 효력이 그대로 유지되지만 그 변경 후에 변경된 취업규칙에 따른 근로조건을 수용하고 근로관계를 갖게 된 근로자에 대한 관계에서는 당연히 변경된 취업규칙이 적용되어야 하고 기득이익의 침해라는 효력 배제 사유가 없는 변경 후의 취업 근로자에 대해서까지 그 변경의 효력을 부인하여 종전 취업규칙이 적용되어야 한다고 볼 근거가 없다.

위와 같은 경우에 취업규칙 변경 후에 취업한 근로자에게 적용되는 취업규칙과 기존 근로자에게 적용되는 취업규칙이 병존하는 것처럼 보이지만, 현행의 법규적 효력을 가진 취업규칙은 변경된 취업규칙이고 다만 기존 근로자에 대한 관계에서 기득이익 침해로 그 효력이 미치지 않는 범위 내에서 종전 취업규칙이 적용될 뿐이므로, 하나의 사업 내에 둘 이상의 취업규칙을 둔 것과 같이 볼 수는 없다.

또 근로기준법 제28조 제2항은 하나의 사업 내에 차등 있는 퇴직금제도의 설정을 금하고 있으나, 변경된 취업규칙의 퇴직금제도가 기존 근로자의 기득이익을 침해하는 것이어서 이들에게는 그 효력이 미치지 않고 부득이 종전 제도의 적용을 받게 됨으로써 이러한 기득이익이 없는 취업규칙 변경 후의 취업근로자에게 적용되는 퇴직금제도와 별개의 퇴직금제도를 적용하는 결과가 되었다고 하여도, 이러한 경우까지 위 법조에서 금하는 차등있는 퇴직금제도를 설정한 경우에 해당한다고 볼 수는 없는 것이다.

는 변경된 취업규칙이 효력이 있다고 하였다.

이럴 경우 하나의 사업장에서 변경 이전의 근로조건과 변경 이후의 근로조건이 병존하는 현상이 발생한다. 만약 퇴직금지급률을 누진제에서 법정제로 변경한 경우 종전의 근로자들은 누진제를 적용받지만 변경 후 새로 입사한 근로자들은 법정제를 적용받게 된다. 이것이 퇴직금차등제도 금지에 해당하는지에 대하여 판례는 기득이익을 보호하기 위한 것이므로 차등제도에 해당하지 않는다는 해석을 하고 있다.

문의_ (02)521-5454